

审理法院开始将关于合理开支赔偿的恶意诉讼责任作为反诉受理。但是，该《批复》未就合理开支之外的其他经济损失能否一并提出予以明确，实务中的理解与适用仍有分歧。本质上，无论是合理开支还是其他经济损失，均为反诉方因相对人的恶意诉讼行为遭受的实际损害，该基点不以诉讼请求赔偿的损失类型不同而改变。故而《批复》虽仅对“合理开支”的损害类型进行列举，但如有其他损害，亦可一并提出。同理可参见《全国法院民商事审判工作会议纪要》第二十六条之股东代表诉讼的反诉，股东依据《中华人民共和国公司法》第一百五十一条第三款的规定提起股东代表诉讼后，被告以原告股东恶意起诉侵犯其合法权益为由提起反诉的，人民法院应予受理。

从反诉的法律规定与法理学依据来看，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条第一款、第二款中规定，反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围。反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实。恶意诉讼责任能否以反诉形式提出，重点在于如何对两诉之间存在事实或法律上的牵连性进行界定：(1)关于相同法律关系。恶意诉讼责任纠纷与著作权、商标权、专利权等侵权纠纷系并列于知识产权权属、侵权纠纷案由下的独立案由，请求权基础不同，但均可抽象为知识产权侵权法律关系。具体到个案中，被告的知识产权也可能因原告的恶意诉讼行为受到侵犯，被告提起恶意诉讼责任的请求权基础暗含自有的知识产权权利。(2)关于因果关系。正因本诉系出于不正当目的、无事实根据和正当理由而提起，导致被告遭受损失，被告才会提起反诉，前、后诉具有因果关系上的继发性。(3)关于牵连性。恶意诉讼责任中，本诉所依据的权利基础与侵权事实，多为反诉所反驳或推翻，二者具有事实上的牵连关系；反诉请求与本诉请求相排斥、抵销或吞并，二者具有法律效果上的牵连关系。

基于此，法院应当准许恶意诉讼责任通过反诉形式提出，由同一合议庭与本诉合并审理，一则有利于从正反两面查明案件事实，综合全案证据

确定赔偿 范围；一则有利于实现制度的诉讼防御功能，防止矛盾判决、程序空转，压缩

诉讼周期，实现诉讼效益。

二、“恶意”认定标准

恶意诉讼本质上是侵权行为，应当符合侵权责任构成的四要件，即主观恶意、侵害行为、损害后果及侵害行为和损害后果之间具有因果关系。实务难点与争点在于“恶意”的认定标准。《中华人民共和国民法典》侵权责任编中并无“恶意”的表述，因此需在“过错”的概念范畴内对“恶意”进行考量，同时结合恶意诉讼责任的定义，则恶意的主观过错程度肯定大于一般故意，“恶意”认定至少包含两个要素：“以追求他人之损害为目的”的不法动机与“明知自身诉求缺乏法律依据或事实基础”的主观认知。

认知因素直接影响到对于目的因素合理性的判断，应当从严解读。首先，权利人对于权利基础瑕疵应当是明知的，“间接故意或者过失”除外。知识产权较之一般民事权利更具法定性、专业性与无形性，权利人对于知识产权权利的类型、内容与边界的认知无法实现准确与周延，难以对自有或他人知识产权的保护边界进行定位。如对其诉权轻易施以主观限制，则会引发权利人惮于诉讼、侵权人恶性报复的反效果。其次，权利人据以提起诉讼的知识产权被宣告无效或撤销，并不当然推论出“明知”权利存在瑕疵。知识产权的取得既受到权利人对于权属认知的影响，又受到其他权利人对于其是否侵害自有在先权利的判断，最后取决于行政机关的审查，各方主体对于事实掌握、效力认定与利益平衡的标准不一，极易导致知识产权的权属状态变动。对此应进一步对被宣告无效或撤销的原因进行区分：对于恶意抢注、未事先进行合理审查等不当取得权利的，方可认定权利人具有明知的过错。再次，对于权利人权利与他人的在先权利或其他类型的权利相冲突的，不宜直接认定为具有主观恶意。知识产权的权利客体多样化，同一标识可以表现为商标权、著作权甚至商品名称、企业名称等多种权利形态，并由不同主体在不同时期取得。通常情况下，如各权利人对于自身权利的取得与使用符合法律规定，则可以在相应权利范围内继续享有知识产权。权利人间因此产生争议的，不以恶意诉讼论。最后，对于“恶意”的认定，因个案细节不

同而难以机械统一。法官应当秉持审慎、克制的原则，综合考量诉讼全貌与客

观行为表现进行裁判：恶意的认定不应局限于某个诉讼环节甚至某个案件，而应尽量从权利的取得与行使、维权的方式与后果等方面进行全方位考察，关注到关联案件中的诉讼表现。对于行为人的诉讼动机、认知水平、行为表现与抗辩事由则参考“合理人”“良家父”的标准作综合评价。

申言之，解决知识产权恶意诉讼的实务困境，更好发挥恶意诉讼责任的反制效用，一则应着力优化诉讼程序，扩大反诉受理范围，为制度运行提供程序便捷；一则应尽快明晰“恶意”认定标准，为法律适用构建实体法依据。

编写人：广东省深圳市罗湖区人民法院 蒋璐璐

具有地域性特点商品通用名称的判定应以 名称所表达的主要含义确定名称属性

——陆某诉A县原老附小汤包馆、潘某擅自使用
与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢
等相同或者近似的标识案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

安徽省高级人民法院(2023)皖民申8998号民事裁定书

2. 案由：擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审被申请人):陆某

被告(被上诉人、再审申请人):A县原老附小汤包馆、潘某

【基本案情】

某师专附属小学(原A县师专附属小学)始创于1926年。2010年该校建立新校区,2016年该地区成立5个小学教育联盟,官方称呼某师专附属小学等为附小北校联盟,附小南校等为附小南校联盟。当地居民一般将某师专附属小学(文明街x×号)称为“老附小”,该称谓出现时间在2010年至2016年之间。经至某师专附属小学及周边现场查看,在文明街经营的店铺多数带有“老附小”文字。陆某自1992年开始在A县某街经营汤包店,并于2015年开设“老附小汤包”(体育路店),2021年开设“老附小汤包”(××店)。在案证据证明,陆某最迟从2015年8月开始在其经营的汤包店门头招牌使用“老附小汤包”标识,陆某在某外卖平台、微信公众号上持续进行过店铺推广宣传,其中2017年10月顾客评价所附照片中也能看出店面门头为“老附小汤包”字样。2021年6月,陆某以“老附小汤包”名义赞助过“A县马拉松比赛”。2022年9月,A县人民政府公布陆某经营的陆氏汤包为第七批县级非物质文化遗产名录及代表性传承人名录。

另查明,潘某及其家人长期经营餐饮小吃,早期也在某师专附属小学(文明街33号)附近经营餐饮店。2018年,潘某注册“A县潘某早点小吃店”个体工商户。2021年,潘某开始使用“老附小灌饼汤包”门头招牌,并于2022年1月7日将其个体工商户名称变更为“A县原老附小汤包馆”,同时,开设“原老附小汤包馆”(××总部店)。2022年1月10日,A县原老附小汤包馆获得食品经营许可。

【案件焦点】

A县原老附小汤包馆、潘某案涉行为是否对陆某经营的“老附小汤包”构成不正当竞争。

【法院裁判要旨】

安徽省利辛县人民法院经审理认为:“老附小”是位于文明街xx号的某师范高等专科学校附属小学的简称,同时,经A县当地公众长期使用,已成为公众认可的

A 县当地的地名，其指代的地理位置是某师范高等专科学校附属小学在文明街××号的校区及周边。另查明，潘某及其家人长期经营餐饮小吃，早期也在某师范高等专科学校附属小学附近经营过餐饮店。“老附小”作为地名，陆某无权禁止他人使用，原老附小汤包馆使用“老附小汤包”的行为不构成不正当竞争。

安徽省利辛县人民法院根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第六条第三项之规定，判决如下：

驳回原告陆某的诉讼请求。

陆某不服一审判决，提起上诉。

安徽省亳州市中级人民法院经审理认为：陆某长期在其经营的汤包店门头使用“老附小汤包”标识，且经过其多年经营并在美团、大众点评等平台及线下持续宣传、推广，已使公众对其销售产品形成特定联系。当地居民提及“老附小汤包”即指向陆某在当地经营的汤包店。陆某所经营使用的“老附小汤包”标识，具有识别商品和服务来源的功能，在A 县区域范围内汤包经营行业具有一定影响力，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项规定的“有一定影响”的服务、商品名称。原老附小汤包馆使用“老附小汤包”的行为构成不正当竞争。

安徽省亳州市中级人民法院根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销安徽省利辛县人民法院一审民事判决；

二、A 县原老附小汤包馆立即停止在店铺招牌、餐具、店名装潢等对外宣传中使用与“老附小汤包”相近似名称的行为；

三、A 县原老附小汤包馆于本判决生效之日起十日内赔偿陆某经济损失及合理维权费用共计20000元；

四、驳回陆某的其他诉讼请求。

宣判后，A 县原老附小汤包馆、潘某提出再审申请。

安徽省高级人民法院同意二审法院裁判意见，裁定：

驳回A县原老附小汤包馆、潘某的再审申请。

【法官后语】

通用名称的认定既是法律事实的认定，也蕴含着价值判断，背后是个体利益和群体利益博弈的体现。商标法语境下，通用名称是指反映一类商品与另一类商品根本区别的规范化称谓，换言之，其只能指代某一类商品，无法识别该产品背后的具体经营者。《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”在商标侵权纠纷中，通用名称抗辩是重要的正当使用抗辩事由。我国司法实践中，通用名称又分为法定通用名称和约定俗成的通用名称。法定通用名称是指国家法律中已经明确规定的通用名称；而约定俗成的通用名称判断依据较为多元，通常包括相关公众的普遍认知、词典记载等。

一、关于法定通用名称的认定

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一款中规定，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。“法定”因其是一个较为宽泛的概念，其既包括法律规定，也包括国家标准、行业标准等规范性文件，而实践中需要准确把握“法定”的范围。尤其是行政机关所出具的官方文件较为多样，既包括规定、规范、标准等，也包括批示、复函等，对于何种文件可以作为法定通用名称的认定依据较难把握，其合理性应从文件的法律效力及内容关联性两方面考察。一是官方文件应具有对某一行业或某类主体普遍适用的法律效力，而非针对某一特定主体或特定问题的具体规定或解释。二是官方文件应具有将某一标识作为《商标法》上通用名称的意思标识。

二、关于约定俗成的通用名称的认定标准

法定通用名称往往存在较为明确的规定和标准，难以把握的是约定俗成的

通用名称的认定。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定,“.....相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称.....”实践中,可以从以下几个方面考察:

一是“相关公众”应当以该商品或服务的相关消费者以及与经营有密切关系的经营者为判断主体。从通用名称的性质来说,相关公众的普遍认可和接受是认定通用名称的主要标准。对于“相关公众”的范围,不同法律规定中有不同的表述,《商标法》第十三条、第十四条“为相关公众所熟知的商标”“相关公众对该商标的知晓程度”中提到了“相关公众”。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定,相关公众主要是指与案涉标识有关的消费者和有密切关系的其他经营者。《关于驰名商标保护规定的联合建议》中则指出,相关公众包括但不限于消费者、销售人员和其他案涉标识的经营者。虽然相关法律对于“相关公众”的范围进行了限定,但表述过于空泛,实践适用中仍然存在一定争议。有学者认为,商标能否发挥作用完全取决于消费者心理,而非社会公众对此态度。^①但从相关规定及实践操作看,消费者并非认定通用名称的唯一“相关公众”,特定地域、行业的生产者、经营者也可以成为通用名称的判定主体。^②笔者认为,诉争商标是否构成商标通用名称的考察对象包括有关消费者以及与经营有密切关系的相关经营者。“有关消费者”一般可以理解为依托产品或服务而限定的具有特定消费习惯或特定身份的实际消费者、潜在消费者等,同时还可能需要考虑风俗习惯、历史因素、行业分布等因素予以限定。

二是关于“相关公众”的考察地域范围一般应以全国作为地域范围,但对于具有地域性特点的商品通用名称的认定可以通过考量地域性特点、历史文化等多种因素,以特定区域及相关人群为标准,而不必拘泥于全国范围。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第二款规

^① 鹏学龙:《商标法的符号学分析》,法律出版社2007年版,第113页。

②张雪松、周波：《商品通用名称的认定和商标类型区分》，载《人民司法·案例》2014年第10期。

定，约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。然而，由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，法院可以认定其为相关市场的通用名称。对于一般商品通用名称的审查，应坚持通用名称的广泛性及于全国，但对于具有地域性特点的商品通用名称，在判断其是否具有广泛性时，应考虑商品所涉及地理环境、风俗文化、历史因素，以特定区域及相关人群为标准。

对“某一名称能够指代一类商品的”的理解应当达到“主要含义”标准。“主要含义”是指以名称所表达的主要含义确定名称属性，即当该标志的主要含义指向商品生产者，即可认定其为商标，若该标志的主要含义指向某一类或某一类别的商品，则可以认定其为通用名称。商标语境下的通用名称与商标功能有着直接联系。识别商品来源是商标最基本、最原始的功能，如果商标失去了这种识别功能，就失去了其“显著性”，就此沦为没有识别功能的“通用名称”。本案中，按照“主要含义”标准，消费者在购买“老附小汤包”时，若相关购买者认为其主要含义是表达一类汤包店的代称，则便可以对其进行通用商标认定。

编写人：安徽省亳州市中级人民法院 王文伟 卞岩岩

茶饮行业商品商标与服务商标权利边界的认定

—— 某甲公司诉某乙公司、何甲侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州知识产权法院(2023)粤73民终1587号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某甲公司

被告(上诉人): 某乙公司

被告: 何甲

【基本案情】

某甲公司享有第4x0号“Linlee”商标、第5××3号“LINLEE”注册商标专用权,核定使用服务类别为第43类。2022年4月,某甲公司发现某奶茶店(经营者何甲)等48家店铺,均为某乙公司的加盟店铺,在店铺门头、店铺装饰、产品介绍、产品杯身等处使用“Lunlei”“LUNLEI”标识。某甲公司主张某乙公司及何甲未经某甲公司授权,擅自使用与“Linlee”近似的商标,造成消费者的混淆误认,构成对某甲公司注册商标权的侵害,请求法院判令两被告立即停止侵权行为,连带赔偿某甲公司经济损失及合理开支300万元。某乙公司辩称其从2021年开始,申请注册了“LUNLEI”“抢擂”等系列商标,某乙公司与某甲公司的商标在发音、含义等方面都有较大的区别,不构成相同或类似商品上的近似商标;某乙公司注册的商标是在2021年5月开始使用,属于在先使用商标。请法院驳回某甲公司的诉讼请求。

【案件焦点】

1. 被诉侵权标识与某甲公司主张的注册商标是否构成近似; 2. 被诉侵权标识是否属于合法规范使用; 3. 被诉商品商标的使用与某甲公司服务商标的使用在类别上是否构成相同或类似。

【法院裁判要旨】

广东省广州市花都区人民法院经审理认为:涉案48家加盟某乙公司的餐饮店铺,在店铺门头招牌、墙壁装潢、海报、点餐牌使用“LUNLEI”标识,杯身、杯环使用“Lnleri”标识,被诉侵权标识“Lnlei”“LUNLEI”与某甲公司的第4××0号、第5××3号商标相比,均为字母构成,其中有四个字母相同,双方商标在文字构成、整体外观等方面相近,且双方当事人同处于广东省,

因发音相似，更加大了消费者对双方商标发生混淆的可能性，故被诉侵权标识与某甲公司注册商标构成近似。

某乙公司在第43类服务上已经获得核准注册的第5××5号“抡擂”、第5××0号“”、第6××4号“手打柠檬茶”注册商标正常规范使用当然不构成侵权，但是在实际使用中，某乙公司及其加盟商将“”Lenlei”“LUNLEI”标识作为商标单独使用，或者将中文“抡擂”缩小而突出使用“L mlei i”，并非按照核准注册商标的构成使用，故被控侵权标识并非对某乙公司注册商标的合法使用。

关于被诉商品商标的使用与某甲公司服务商标的使用在类别上是否构成相同或类似的问题，需要结合商标类别的权利边界对被诉标识的具体使用行为进行分析。法院认为，商标是区分商品或服务来源的标志，商品商标与服务商标是两个不同的商标类别，商品商标通常直接标注于有形实物商品上，用于识别商品提供者；服务商标因服务的无形性特点往往附着于服务相关的场所招牌、工具等物品上，用于识别服务提供者，二者的识别对象不同，其获准注册时所核准的使用范围也不同。本案中，某乙公司将“抡擂LUNLEI”（第21类、第30类、第32类）商标，“”（第16类、第21类）商标，“Lmlei”（第16类、第25类、第28类）商标，应用于识别商品来源的商品商标扩展使用至用于识别服务来源的物品上，是否构成合法使用，法院评析如下：首先，涉案的加盟店铺经营模式是基于特定消费者的购买要约而制作、提供食品，点单或外带均在线下线上店铺完成，其经营行为属于餐饮服务的提供行为。其次，根据《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条的规定，服务商标的使用是指为提供服务而在服务场所、服务招牌、服务工具、带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品、带有服务商标的账册、发票合同等商业交易文书、广告及其他宣传用品上的使用，该种使用具备指示服务来源的作用。被诉标识“Lemlei”“LUNLEI”均被以凸显方式附着于店铺的店招、店内装潢（墙面装潢、灯箱装潢、点餐牌）、海报、餐具（杯身、杯环、包装袋等）、赠品等有

形物品之上。该些物品并非某乙公司之商品商标所指向的商品或者指示其商品来源所必须，而是用于提供餐饮服务的工具、用品等，附着于其上的标识也并非用于指示该物品的来源，而是用于指示餐饮经营者的服务来源。最后，某乙公司及其加盟商将被诉侵权标识用于柠檬茶等饮料餐饮服务，与某甲公司第4××0号、第5××3号服务商标核准使用类别第43类相同，某乙公司对其商品商标的使用已超出该类别商标用于指示其商品来源的必要范围，逾越了商品商标的权利边界，并落入用于识别服务来源的服务商标的权利边界从而产生标识服务来源的效果。综上，应认定某乙公司对被诉标识的使用与某甲公司服务商标的使用在类别上构成相同，某乙公司不属于合法使用注册商标。

经营者应本着诚实信用、禁止混淆、公平竞争的原则，恪守商品商标与服务商标的权利边界，谋求共存发展。现某乙公司作为同业经营者，明知某甲公司的服务商标具有较高知名度，仍逾越权利边界，变更注册商标使用方式，将其商品商标扩展使用至餐饮服务及相应加盟招商宣传之中，其行为已超出其商品商标指示其商品来源的必要范围，产生标识其服务系源自某甲公司或与某甲公司有特定关系者的效果，导致混淆误认。某乙公司主观上具有攀附某甲公司服务商标商誉的故意，客观上亦造成相关公众的混淆误认，构成对某甲公司服务商标专用权的侵害。

广东省广州市花都区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四条、第四十八条、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条、第十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条规定，判决如下：

一、被告某乙公司、何甲于本判决生效之日起立即停止侵害原告某甲公司第4x×0号、第5××3号注册商标专用权的行为；

二、被告某乙公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告某甲公司经济损失及维权合理开支合计1500000元；

三、被告何甲于本判决生效之日起十日内赔偿原告某甲公司经济损失及维

权合理开支合计8000元；

四、驳回原告某甲公司的其他诉讼请求。

某乙公司不服一审判决，提起上诉。

广州知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

由于奶茶等饮品的制作方法较为直观，各品牌间相互模仿产品也更为容易，使得商标的重要性尤为突出。

商标是区分商品或服务来源的标志，商标按照识别对象的不同可以分为商品商标与服务商标，两者的权利边界看似泾渭分明，但当服务商标使用的载体或者提供服务的结果表现为商品时，服务商标与商品商标便可能由于权利人不规范使用其商标而产生权利冲突。^①茶饮行业侵权行为的表现方式较多，商品商标与服务商标各自的权利范围如何确定，侵权判断的标准又应当如何把握，实践中存在一定难度和争议。

一、商品商标与服务商标权利法律界限

根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商品商标是指商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上采用的，用于区别商品或服务来源的，由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合，或上述要素的组合，具有显著特征的标志。从商品商标定义可知，商品商标通常直接标注于有形实物商品上，用于识别商品提供者。

《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条第一款规定，在下列情形中 使用服务商标，视为服务商标的使用： (1)服务场所；(2)服务招牌；

①凌宗亮：《判断服务商标是否侵害商品商标应区分使用情形》，载《人民司法》2014

(3)服务工具；(4)带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品；(5)带有服务商标的账册、发票合同等商业交易文书；(6)广告及其他宣传用品；

(7)为提供服务所使用的其他物品。服务商标是指服务的提供者在其提供的服务上采用的，用于区别服务来源的，具有显著特征的标志。服务商标因服务的无形性特点往往附着于服务相关的场所招牌、工具等物品上，用于识别服务提供者。

二、商品商标与服务商标类别区分

从商品商标和服务商标的定义可知，商品商标的使用主体一般是商品的生产者或经营者，而服务商标的使用主体一般是服务的提供者。商品商标与服务商标二者的识别对象不同，其获准注册时所核准的使用范围也不同。

商品是用来交换的能够满足人们某种需要的劳动产品。商品生产后的销售环节是商品进入流通领域的必经步骤和应有之义。《类似商品和服务区分表》在第三十五类的注释部分明确规定了商品销售不视为服务，即商品销售为商品所附带的行为，在销售环节对商品商标的使用，不应当视为提供服务。

服务是不同经济主体之间通过使用权的让渡获得运动形态的使用价值，并使服务消费者获得消费利益或满足感。服务的基本特征包括：生产与消费的同步性(二者在时间上不可分离)；无形性和不可感知性；差异性和质量的不确定性；不可储存和无法运输性^①。服务不以“物”，而是以“活动”提供特殊的使用价值，往往即时生产和销售，让消费者获得即时的消费体验和满足感，与需要进入流通领域“待售”的商品相区别。

三、茶饮行业商品商标与服务商标边界的认定

商标专用权是指商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上进行专有使用的权利。因此，商标专用权权利范围主要通过商标标识和商标所识别的商品或服务两个要素进行界定：一方面商标使用权的范围限于在核准注册的商品上使用核准注册的商标；另一方面商标禁用权的范围限于

禁止他人在类似商品上使用相同或近似的商标或者在相同商品上使用近似商标。在商品商标与服

①庄丽娟：《服务定义的研究线索和理论界定》，载《中国流通经济》2004年第9期。

务商标中的商标标识构成相同或近似的情况下，二者的权利范围的界限主要在于商标所识别商品与服务的区分，即如何区分商品提供行为与服务提供行为。当服务行为与提供该服务所使用的商品之间存在特定联系时，二者可视为类似，商品与服务的类似判断无法直接参考分类表，而需从以下方面来辨明：商品与服务在性质上的相关程度；二者在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面的一致性；是否会导致相关公众误认为该商品和服务来自同一市场主体或者有某种联系的市场主体。

因为茶饮行业的商业模式较为特殊，有些店面仅提供外带服务，有些店面还会另外提供堂食服务，有些提供多环节多内容的复杂服务，提供服务活动的同时产生或者附带产品。茶饮行业商品商标和服务商标的区分，落脚点仍然在于对商业模式的探究，不同的商业模式导致在判断商标使用行为所属类别时存在差异。这使得判断在杯身、袋子、装潢、门店招牌上使用商标的行为，究竟是属于在第43类餐厅、酒吧服务、茶馆等类别上使用，还是属于在第29类(如奶茶、奶饮料等)、第30类(如咖啡、茶饮料等)、第32类(如柠檬水等)饮品上使用存在争议。鉴于茶饮行业特殊经营模式，应坚持个案认定原则，综合考虑商标的实际使用情况和相关公众的认知来认定商品商标与服务商标的边界。

第一种商业模式，店铺主要的收入来源是外带的饮品，店铺所出售的商品大多数由消费者直接带走在经营场所之外的地方饮用，消费者注重的是商品而不是续杯及店内环境服务时，应当将外包装杯子、袋子、吸管上使用的商标认定为商品商标。

第二种商业模式，即本案“LUNLEI”手打柠檬茶店铺的经营模式，现场制作、直接销售，同时配有点单、吧台座位等服务。被诉标识“„ Lmlei”“LUN- LEI”均被以突显方式附着于店铺的店招、店内装潢(墙面装潢、灯箱装潢、点餐牌)、海报、餐具(杯身、杯环、包装袋等)、赠品等有形物品之上。店铺生产的饮料产品即时生产、即时销售，让消费者获得即时的消费体验和满足感，符合生产与消费的同步性的服务基本特征。虽然产品杯身、

袋子上标识了“LUNLEI” 商标，但从整体看，饮料产品是“提供餐饮服务”的服务内容和结果，是提供服

务的一个环节，且即时生产和销售淡化了在“流通”过程中“待”销售的商品特性，整体商业模式为“提供食物和饮料的服务活动”，符合无形性和不可感知性，因此对被诉侵权商标的使用应视为服务商标使用。本案被告不规范地将应用于识别商品来源的商品商标，以凸显方式附着于店铺的店招、餐具等有形物品之上，其行为已超出其商品商标指示其商品来源的必要范围，产生标识其服务系源自原告或与原告有特定关系者的效果，导致混淆误认。被告对其商标的使用逾越了商品商标的权利边界，应认定被告不属于合法使用注册商标。

本案厘清了商品商标与服务商标的权利边界，严厉打击攀附知名企业商誉行为，充分体现了严格知识产权保护的司法导向，有助于引导经营者消除“投机”心态、坚持合规经营，共同营造公平有序、充满活力的市场环境。

编写人：广东省广州市花都区人民法院 陈雅敏

刮去溯源码是否构成侵害商标权的认定

——广州某化妆品有限公司、王某诉黄某、浙江某网络
有限公司侵害商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2023)浙11民终127号民事判决书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):广州某化妆品有限公司、王某

被告(被上诉人):黄某、浙江某网络有限公司

【基本案情】

黄某在他人处购得已“刮去溯源码”的广州某化妆品有限公司享有商标权的化妆品后，未经广州某化妆品有限公司授权，将其放到某网交易平台的浙江某网络有限公司注册店铺进行销售，同时注明“厂家区域保护需要割掉批号谅解”“无备注有码的都代表要割批号”等字样。

【案件焦点】

黄某未经注册商标专用权人许可，销售“刮码”产品是否构成侵害商标专用权。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市莲都区人民法院经审理认为：首先，黄某销售的商品系正品，广州某化妆品有限公司提供的证据无法证实系黄某对案涉正品进行了刮码处理，根据商标权用尽原则，黄某销售刮码正品的行为并不构成对广州某化妆品有限公司商标权的侵权。其次，黄某在销售上述产品时，未经许可引用了广州某化妆品有限公司的宣传手册及宣传图片，已构成对广州某化妆品有限公司上述图片著作权的侵害，根据图片类型，知名度，侵权行为的性质、后果及广州某化妆品有限公司为维权支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿金额为7000元（含合理费用）。最后，黄某是否构成不正当竞争，在市场竞争过程中，经营者不负有维护其他经营者商业模式的义务，目前证据无法证实被告黄某系刮码的行为人，同时黄某在销售案涉产品时对产品的实际情况进行了说明，给予了购买者选择权，广州某化妆品有限公司提供的证据无法证实被告黄某在此过程中违背了诚实信用和公认的社会道德并不正当地攫取他人可以合理预期获得的商业机会，故广州某化妆品有限公司诉请黄某构成不正当竞争，于法无据，法院不予支持。关于浙江某网络有限公司是否构成共同侵权。浙江某网络有限公司作为交易平台提供者，已经尽到了事先注意义务，对商品发布者的身份进行了核实，在广州某化妆品有限公司发函后也进行了复函，并已确认案涉商品链接下架的事实，已尽到了网络服务提供者的义务，无需承担侵权责任。

浙江省丽水市莲都区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条,《中华人民共和国著作权法》第十条、第五十二条、第五十三条、第五十四条,《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条、第二十六条之规定,判决如下:

一、被告黄某于本判决生效后十日内赔偿原告广州某化妆品有限公司经济损失7000元(含合理费用);

二、驳回原告的其他诉讼请求。

广州某化妆品有限公司、王某不服一审判决,提起上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为:根据当事人的诉请及本案查明的事实,本案案由为侵害商标权、著作权侵权及不正当竞争纠纷。根据双方的诉辩意见,本案二审的争议焦点为:(1)被诉侵权行为是否构成商标侵权;(2)被诉侵权行为是否构成不正当竞争;(3)浙江某网络有限公司是否应承担赔偿责任。

关于争议焦点一,本案中,案涉被诉侵权产品是否为正品系判断是否构成侵害商标专用权行为的基础。广州某化妆品有限公司称黄某侵害其商标专用权,应承担证明所购案涉被诉侵权产品并非正品的举证责任。广州某化妆品有限公司以购买的案涉侵权产品刮码后无法检验是否为正品为由,主张被诉产品为非正品,但二维码和生产批号部分信息是否被刮除,与案涉产品是否为正品之间没有直接关系,广州某化妆品有限公司既未申请对案涉侵权产品进行鉴定,也未提供被诉产品为非正品的其他证据,而黄某提供了聊天记录等予以证明商品来源合法,广州某化妆品有限公司应当承担举证不能的不利后果。鉴于一审法院认定案涉产品为正品,广州某化妆品有限公司二审亦未对此提起上诉,故,一审认定案涉被诉侵权产品为正品并无不当,法院予以支持。虽然被诉侵权产品二维码和生产批号部分信息被刮除,但案涉产品来源信息清晰可见,其他如生产日期、保质期、成分等化妆品类产品的必要信息,消费者亦可通过外包装上的标注获取。在被诉侵权产品为正品的情况下,该商品来源于广州某化妆品

有限公司属于客观事实，不会导致相关公众对产品的来源产生混淆。此外，消费者对从黄某网店购买的产品质量、包装有一定预期，也知晓其难以享受广州某化妆品有限公司商业模式下的全部服务。综上，在确认案涉产品来源合法的前提下，黄某的销售行为不会贬损其品牌价值或产生其他负面影响，可以适用商标权用尽原则，不构成商标侵权。

关于争议焦点二，首先，黄某以合法方式获得广州某化妆品有限公司产品后，广州某化妆品有限公司已经通过销售产品获取了利润，故黄某的销售行为未损害广州某化妆品有限公司利益。其次，消费者在明知购买的系刮码产品的前提下而自愿购买，即其愿意放弃二维码和生产批号的完整性以及广州某化妆品有限公司全部服务，以较低价格购入，是消费偏好的选择结果。在确认案涉被诉侵权产品为正品的情况下，如果产品质量出现问题，广州某化妆品有限公司及黄某均不能因产品被刮码而免责。综上，黄某的销售行为并未损及消费者利益和社会公共利益。最后，在市场竞争中，商业主体之间的竞争势必产生摩擦和损害，经营者不负有维护其他经营者商业模式的义务。广州某化妆品有限公司称其商业模式受到影响，但并不能据此否定黄某销售行为的正当性。此外，黄某在销售中未使用案涉产品作为店铺名称、头像等，不存在引流之故意。综上，黄某销售行为并未违背诚实信用原则和公认的商业道德。一审认定黄某销售刮码产品的行为不构成不正当竞争并无不当。

关于争议焦点三，广州某化妆品有限公司主张浙江某网络有限公司构成帮助侵权，应承担赔偿责任。法院认为，浙江某网络有限公司作为网络交易平台服务提供商，尽到了事前审查义务。广州某化妆品有限公司投诉后，浙江某网络有限公司予以回复；在获悉黄某涉嫌侵权后，采取了禁售措施，删除、断开了被诉侵权产品链接，故浙江某网络有限公司不存在明知或应知侵权行为存在而不采取措施的情形，广州某化妆品有限公司现有证据无法证明浙江某网络有限公司存在帮助侵权的故意。广州某化妆品有限公司主张浙江某网络有限公司构成帮助侵权的主张，缺乏事实依据，法院不予支持。浙江某网络有限公司关于其不构成侵权的抗辩，理由成立，法院予以采纳。另，关于王某的上诉请求，

一审判决并未涉及王某的实体权利，王某也未对此提起上诉，法院不予评判。

综上所述，上诉人的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在市场行为中，产品的生产者为了实现对产品的溯源、价格管控、遏制串货、提供售后服务等目的，会在其产品上“赋码”，作为其销售和管理体系的一环。而产品的代理商或销售者为实现扩大销量、赚取利润等目的，会以折扣让利等方式从产品低价区域转售相关产品，实现利益最大化。因转售行为可能违反代理商对生产商所负的区域价格管控义务，并可通过相关“编码”溯源，故代理商会对相关产品“刮码”处理。对于此类销售“刮码”产品的行为，销售者是否构成侵犯商标权或不正当竞争，应当在商标权用尽原则及所保护法益的必要性上综合考量。

一、销售“刮码”产品是否适用商标权用尽原则

商标权用尽又称商标权穷竭，是知识产权立法与司法实践中普遍确立的一项重要原则。其具体是指商标权人对原商标的商标权在其将商品合法售卖后即宣告终止，他人再次在市场上售卖或使用该商品不受限制，以此平衡公共利益和商标权利人的权利保护，促进商品流通。

对于商标权用尽如何适用，应当回归商标的基本功能，即“来源识别”功能中，当销售行为不损害商标“来源识别”功能时，即“权利用尽”，商标权人对此无权干涉。具体而言，应满足两个基本条件：第一，使用的商标仍是原商标。即再次销售的商品商标与首次销售的原商品商标相同，不存在反向假冒等情形。第二，商品本身的品质未发生变化。商标的识别功能，不仅体现在标志同一上，其还蕴含着贴附于该商标商品的品质、声誉等，当改变商品中的部分要素，即可能对其识别功能造成损害。因此，只要再次销售行为没有直接或

间接地改变商标商品的原始状况或商标权人的声誉,则可适用商标权用尽原则。本案中,商品仅二维码和生产批号部分信息被刮除,但仍使用“某妮”商标进行销售,商标在转售前具有-致性,且涉及产品质量的生产日期、保质期、成分等化妆品类产品的必要信息清晰可见,消费者亦可通过外包装上的标注获取,即商品本身的状态、包装、品质未发生本质变化,消费者对该商品的品质及商誉的期待并不会因此降低。此外,在案涉产品为正品的情况下,对于“刮码”情况,销售时告知了消费者产品的真实状态,并未使消费者产生误认或错漏重要信息,对商品来源于广州某化妆品有限公司产品的识别功能无损,故可适用商标权用尽原则,不构成商标侵权。

二、销售“刮码”产品是否构成不正当竞争

一般情况下,当侵犯同一客体时,若《中华人民共和国商标法》能进行救济,则不再适用《中华人民共和国反不正当竞争法》,但《中华人民共和国商标法》与《中华人民共和国反不正当竞争法》的保护客体和立法目的存在区别,故在本案不构成商标侵权的情形下,仍应根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的立法规范对被告的行为进行审查。《中华人民共和国反不正当竞争法》明文规定了七种类型化的不正当竞争行为,但本案被告黄某的销售“刮码”产品行为并不在上述行为中,因此需以一般条款判断该行为的性质。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的立法目的,其已确立起三元叠加的法益保护目标,即保护竞争者公平竞争、消费者自由决策、社会福利最大化的竞争秩序。因此,对被告行为的评价,并不能通过简单认定其“刮码”行为与原告损害间具有因果关系而认定侵权,而应保持司法谨慎与谦抑,以平衡法益保护的理念评价竞争行为。

第一,对市场主体而言,正常的市场竞争行为也会导致其他竞争者的损害。无论是本案原告还是被告,其在参与市场竞争的过程中,必然面临其他竞争者的挑战和经营风险。原告公司所称“刮码”行为破坏了其产品销售和质量管理体系,但该管理体系仅是其参与市场竞争的一种策略选择,是获得交易的机会,而非某种既定的财产权利。且其通过销售产品已经从转售人处获得过收益,先

